


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

**TERMO AUDIÊNCIA**

Processo nº **0044322-96.2016.8.26.0050**  
 Réu **ALLAN BONGESTAB DVORKIN**

Aos 20/04/2017, às 13:30h, na sala de audiências da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Izabel Irlanda Castro Correia Araújo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, AUSENTE o réu ALLAN, devidamente intimado (fls. 85). PRESENTES as testemunhas THYAGO e RENATA.

Presente o Promotor de Justiça, **Dr. Fernando Henrique de Moraes Araújo** e a Defensora Pública em exercício nesta vara, **Dra. Mônica de Melo**.

Iniciados os trabalhos, **foi declarada a revelia do réu**, pois apesar de pessoalmente intimado, deixou de comparecer ao presente ato.

A seguir foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas em comum: THYAGO e RENATA.

Assim sendo, após ser entrevistado por sua defensora, deu-se o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução foi dada a palavra às partes, para pedidos de diligências, por estas foi dito que nada havia para ser requerido.

**Na sequência, foi dado início aos debates, dada a palavra ao Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito:** “MM Juíza, **O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO** ofereceu **DENÚNCIA** em face de **ALLAN BONGESTAB DVORKIN** como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 1º de junho de 2016, às 4h, na Rua Domingos dos Santos Gomes, 490, Aricanduva, São Paulo, **trazia consigo drogas, para fins de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal**, consistentes em 11 eppendorfs contendo 26,5 gramas de cocaína, bem como a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro (v- auto de exibição e apreensão fls. 10/11, laudo pericial provisório fls.12/13 – v. denuncia. Citação (fls. 61/62). Resposta à acusação (fls. 66). Recebimento da denuncia (fls. 71/72). Audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório. É o relatório. Pedese a condenação do acusado. A materialidade delitiva ficou provada, considerando-se especialmente o auto de exibição e apreensão, o laudo pericial provisório e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 86/88 que confirmaram que eram cocaína as substancias apreendidas com o acusado. Da prova oral reproduzida em juízo. O POLICIAL CIVIL THYAGO CURSINO ZAPAROLI disse que o acusado foi visto em uma escadaria e a todo momento saía e voltava para o mesmo local. Resolveram proceder a abordagem em razão dessa atitude suspeita. O local em que ele estava era um conjunto habitacional. Na abordagem foram encontrados com ele 11 eppendorfs contendo cocaína, bem como a


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**
**Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020**

quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro. Ele sempre ia até o conjunto habitacional e depois se dirigia a uma concentração de pessoas – alguns moradores de rua e aparentes usuários de drogas. Viu o acusado realizando a movimentação suspeita uma 3 vezes em cerca de 5min. O acusado estava meio alterado e parecia ter feito uso de drogas. Ele disse que era usuário. Não presenciou o acusado usando drogas, tampouco entregando-as às pessoas que ficavam em volta dele (pessoas que moram na rua, com cobertores e cachimbos de crack). Ele disse que o dinheiro apreendido era proveniente da venda de frango e seria utilizado para comprar drogas. Não localizou drogas no local para onde o acusado ia e depois voltava. Não conseguiu visualizar o acusado vendendo drogas. Só havia drogas no bolso do acusado. Os moradores de rua não tinham drogas, mas tinham cachimbo de crack, bem como dedos com aparência de usuários (v. mídia digital respectiva). A POLICIAL CIVIL RENATA LEVASSI reiterou em essência o teor do seu colega de polícia. Confirmou ter apreendido as drogas – 11 eppendorfs e R\$ 90,00 em dinheiro com o acusado. O acusado confessou que era usuário e também vendia drogas no local dos fatos para sustentar o vício. O local em que ele estava relativamente cheio. Não foram encontradas drogas no local em que ele estava, mas apenas com ele. Ele admitiu que estava ali no local porque é ponto de venda de drogas e por isso ele estava ali para vender (v. mídia digital respectiva). O acusado não compareceu à audiência, fazendo-se revel. Esta a prova produzida que, vista em seu contexto, enseja a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Segundo se apurou na data, horário e local supracitados, **o acusado** trazia consigo drogas, para fins de comércio e entrega a terceiros, quando foi avistando pelos policiais civis em diligências. **O acusado** chamou a atenção dos policiais, devido a suas entradas e saídas repetidas de um determinado local, motivo pelo qual os policiais optaram pela abordagem. Em busca pessoal **no acusado**, os policiais encontraram 11 pinos de cocaína prontos para o comércio e entrega a terceiros, bem como a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais). Ao ser indagado pelos policiais autuantes, **o acusado** confessou informalmente que estava no local vendendo drogas, pois era usuário e traficava para sustentar seu vício. Constatada a prática delitiva, **o acusado** foi detido e preso em flagrante delito, sendo conduzido ao Distrito Policial para registro de ocorrência. Interrogado na fase policial, **o acusado** preferiu o silêncio (fls.06). Não foi ouvido em juízo porque não compareceu para tanto, fazendo-se revel. Ambos os agentes públicos confirmaram ter apreendido drogas e dinheiro com o acusado. A testemunha e policial Renata confirmou que o acusado admitiu ser usuário e também vender drogas para sustento de seu vício, confirmando a finalidade de tráfico de drogas. Resta apenas consideração sobre pena e regime a serem fixados em caso de condenação. A pena poderá ser a mínima: 5 anos de reclusão. Nada a justificar aumento ou diminuição da pena, em qualquer das fases de dosimetria. O regime prisional, conquanto primário, deverá ser o inicial fechado, único compatível com a hediondez e gravidade delitiva, bem nos termos do artigo 59, III, do Código Penal. Posto isto, **pede-se a condenação de ALLAN BONGESTAB DVORKIN, como incurso no artigo 33, caput, Lei Federal n. 11.343/06, com perdimento do dinheiro apreendido para o FUNAD.**”


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

**Dada a palavra à defensora do réu, pela mesma foi dito:** “MM Juíza, o policial civil Thyago, relatou em seu depoimento que foi presa numa escadaria perto de um conjunto habitacional. Perto dele haviam outros usuários de drogas e ele entrava e saía toda hora de um local. Com ele tinha pinos de cocaína e 90 reais em dinheiro. Era um conjunto habitacional grande. Era um ponto de drogas. Estava no começo da escadaria que dava para esse conjunto. Via uma concentração de pessoas e ele descia até o fim da escadaria e depois voltava e um monte de pessoas drogadas em volta. Tinha umas 3 ou 4 pessoas e moradores de rua. Era uma escadaria longa, continuação de uma rua. Ele virava à direita e voltava para a escadaria. Viu ele fazer isso umas 3 vezes durante uns 5 minutos. Estava alterado e confessou que era usuário. Não viu se ele entregava droga para alguém. Ficava muita gente em volta. Ele disse que o dinheiro era para comprar para consumir. Ele disse que outro serviço de manhã e que mexia com frango. Ele disse que estava ali usando. As outras pessoas eram moradores de rua, pessoas com o mesmo tipo daquelas que estão na cracolândia. Ele saía para um local onde não tinha usuários. Ele local foi revistado mas não tinha drogas ali. As outras pessoas que estavam lá foram abordadas mas ninguém estava com droga na revista, apenas com marcas nos dedos e uma com um cachimbinho. A testemunha Renata, policial civil, em seu depoimento relatou que estava em patrulhamento e essa área tem venda de drogas. Era uma escadaria. Foi visto em atitude suspeita entrando e saindo dessa escadaria e foi encontrado com droga. Eram 11 porções de cocaína e tinha 90 reais com ele também. Ele disse que era usuário e que também venderia ali para sustentar o vício. Ele falou isso quando foi perguntado. Não disse a origem do dinheiro. Ele disse que vendia lá. Não se recorda se tinha alguma atividade com frango. Havia outras pessoas no local. Estava bem cheio. Alguns foram abordados. Era um bar de esquina e fica bastante gente lá. Ele subia e descia da escadaria. Não viu quantas vezes ele fez isso. Quando estavam passando é que viram essa movimentação. Deram a volta e acompanharam essa trajetória do movimento na escada. Ele foi abordado no topo da escada. Ninguém confirmou que comprou com ele. Não localizaram drogas no local e nem nas pessoas que ali estavam e que foram abordadas. Ele aparentava ter consumido drogas, mas não estava alterado. O réu embora intimado deixou de comparecer sendo decretada sua revelia, o que entretanto, não pode ser interpretado em seu desfavor em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência e do direito de permanecer calado e de não produzir prova em seu desfavor. **I - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS** O depoimento prestado pelos policiais civil e a pequena quantidade de drogas encontrada com o acusado não sustentam uma condenação por tráfico de drogas. Não se localizou nenhuma droga para onde o acusado descia e não era possível vê-lo, o que pode indicar que estava consumindo no local. Ademais, na revista pessoal e abordagem que foi feita nas demais pessoas que se encontravam no local nenhuma droga foi localizada. Os policiais também relatam que nenhuma das pessoas abordados afirmou ter comprado drogas com o acusado. O próprio acusado teria se declarado usuário e os policiais afirmaram que aparentava ter consumido drogas. Dessa forma não foi produzida prova de que o réu estivesse traficando e a pouca droga que possuía pode ser considerada para seu consumo pessoal. Dessa forma, não há


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

prova suficiente para uma condenação por tráfico. As afirmações dos policiais civis em relação aos fatos ocorridos são por demais genéricas e inconclusivas. Em razão da insegurança jurídica deixada pela situação narrada, defende-se aqui a ideia de que, quando absolutamente isolado e contraditório os depoimentos das agentes responsáveis pela ocorrência não podem suportar uma decisão condenatória. Do contrário, a exceção acaba por transforma-se em regra, permitindo que o aparelho repressor do Estado praticamente decida quem será processado e quem ao final será condenado. Com efeito, não se nega a nobreza da função ou a honestidade da instituição. Pelo contrário, sabe-se que são os grandes responsáveis pela segurança pública de um Estado. Contudo, o processo penal é regido por princípios constitucionais que protegem a liberdade humana e limitam o jus puniendi do Estado Democrático de Direito, o qual tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, qualquer ingerência na esfera pessoal deve estar amparada pela Constituição Federal. Pretende-se argumentar que, um sistema processual penal não pode conter falhas, obscuridades e/ou incertezas. O suporte condenatório deve ser CERTO. A atual sistemática de investigação, que despreza toda prova que não emane dos próprios agentes do estado, sob o pretexto de que ninguém se presta a colaborar com a polícia ou com a justiça (verdadeiro sofisma, pois esta não é uma faculdade e sim um dever do cidadão - o que garante ao policial o direito de exercer a autoridade que se fizer necessária para a colheita da prova) acaba por transferir aos policiais que efetuam a prisão poder imensurável na persecução penal. Se aceito como verdade absoluta o depoimento daqueles, qual a possibilidade de defesa do acusado? O processo penal, sob a ótica constitucional, não pode admitir que a verdade seja posta por uma das partes. In casu, a verdade é posta por aqueles que efetuam a prisão. Ora, por que não acolher a versão do réu em detrimento da versão dos policiais? Por mais honesto que seja, será que um policial iria desdizer o seu parceiro? Se o fizesse, em tese, alguém incorreria em falso testemunho e/ou, eventualmente, em crime de abuso de autoridade. Constata-se, assim, que a condenação baseada exclusivamente em tais depoimentos, fere frontalmente o princípio do contraditório em seu aspecto substantivo, também denominado na doutrina alemã de “PODER DE INFLUÊNCIA”. Diante das circunstâncias colocadas, qual o poder de influência do réu? Nenhum! Destarte, a interpretação atual de autorizar tais testemunhos, isoladamente, revela-se inconstitucional por afronta patente ao contraditório substancial. O professor Fredie Didier Jr., aborda com maestria a temática dos princípios processuais constitucionais, aplicados, com maior razão, ao processo penal: *“O processo é um instrumento de composição de conflito – pacificação social – que se realiza sob o manto do contraditório. O contraditório é inerente ao processo. Trata-se de princípio que pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência; comunicação; ciência) e possibilidade de influência na decisão. Aplica-se o princípio do contraditório, derivado que é do devido processo legal, nos âmbitos jurisdicional, administrativo e negocial. Democracia no processo recebe o nome de contraditório. Democracia é participação; e a participação no processo se opera pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como manifestação do exercício democrático de um poder.*


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

Quais são os elementos que compõe a garantia do contraditório? Esta garantia desdobra-se em duas facetas. A faceta básica, que eu reputo a formal, é a da participação; a garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Isso é o mínimo e é o que todo mundo entende como princípio do contraditório. De acordo com o pensamento clássico, o magistrado efetiva, plenamente, a garantia do contraditório simplesmente ao dar ensejo à ouvida da parte, ao deixar a parte falar. Mas não é só isso. Há o elemento substancial dessa garantia, há um aspecto, que eu reputo essencial, denominado, de acordo com a doutrina alemã, de 'poder de influência'. Não adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do processo; que ela seja ouvida. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do Magistrado – e isso é poder de influência, poder de interferir na decisão do Magistrado, interferir com argumentos, interferir com idéias, com fatos novos, com argumentos jurídicos novos; se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a ouvida, com a participação; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão. Como poderia o magistrado punir alguém, sem que lhe tenha dado a chance de manifestar-se sobre os fundamentos da punição, por exemplo, demonstrando que os fatos em que se baseia o magistrado ou não ocorreram ou não permitem a aplicação da sanção? Seria punir sem ouvir; seria condenar sem dar a chance de defesa. Não é possível a aplicação de qualquer punição processual, sem que se dê oportunidade ao 'possível punido' manifestar-se previamente, de modo a que possa, de alguma forma, influenciar no resultado da decisão". (Curso de Direito Processual Civil, Edições Podivm, Páginas 42/43) De se destacar que o sistemático desprezo da palavra do réu em favor do depoimento do agente isolado viola ainda o princípio in dubio pro reo, já que a contrariedade existente entre estas provas se resolve em condenação e não absolvição. Em sentido oposto, quando a prova da acusação se resume exclusivamente a palavra dos agentes, não havendo razões para reputar como incrível ou inverossímil a defesa apresentada pelos réus e por suas testemunhas é o caso de absolvê-los por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Em recente decisão assim manifestou-se o Tribunal de Justiça de São Paulo, (Apelação nº 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Des. SYDNEI DE OLIVEIRA JR., 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado aos 03 de março de 2011), em caso também envolvendo suposta traficância, e tendo como únicas provas os depoimentos policiais, o qual pela importância se transcreve: "(...) Afinal de contas, as versões apresentadas se chocam e entrechocam, sendo salutar socorrer-se do vetusto in dubio pro reo. Uma vez presente à dúvida, presume-se, sem pestanejar, a inocência do acusado. Afinal de contas, in dubio pro libertate ou libertas omnibus rebus favorabilior est - na dúvida, pela liberdade; ou, em todas as coisas, a liberdade é mais favorecida, já diziam os romanos (CAIO. De regulis iuris. Digesto, Livro 50, Título 17), cujas locuções




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

latinas são precursoras do conhecido e atual *in dubio pro reo* (...)". "(...) não se está sustentado a completa inaptidão do testemunho de policial, em sede de processo criminal. O que se defende é coisa bem outra. Os policiais militares investigadores do fato, como verdadeiros assistentes da parte autora, não têm, sozinhos, em face da própria condição de servirem como longa manus do Ministério Público, enquanto ditam as provas, a isenção suficiente para demarcarem, através de seus exclusivos depoimentos, um justo e razoável juízo de reprovação penal. Admitir-se entendimento outro é o mesmo que fazer ouvidos moucos ao som do retumbante princípio da proporcionalidade, desequilibrando, a não mais bastar, as atuações dos atores processuais, em manifesto e desmesurado prejuízo à ampla defesa do acusado, tornando-o sempre a parte vulnerável da ação penal, com mínimas chances, para não se dizer nenhuma, de se ver livre da imputação (...)" (Grifo nosso) "(...) É certo que os policiais não estão impedidos de depor - e isso nem se discute -, mas, porque prenderam certo acusado, seus exclusivos depoimentos não se apresentam idôneos para um definitivo esclarecimento da verdade processual, ou para embasar, com a segurança desejada, um justo édito condenatório do preso. Não são, certamente, imparciais, ainda mais quando, como no caso, suas falas são desmentidas pelo incriminado (...)". (Grifo nosso)

Conforme se observa, o acórdão supra aplica-se como uma luva ao caso em testilha. As versões dos milicianos não foram confrontadas com nenhuma outra prova trazida aos autos. Assim, imperiosa a absolvição do réu, acompanhando-se consolidado entendimento dos Tribunais: "Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo dúvida, chegando as provas somente ao crível, a justa solução é a absolvição" (RT 453/414). "Para um decreto condenatório, é indispensável a existência de provas seguras, precisas, não bastando suspeitas ou indícios, mesmo que sejam veementes" (JUTACRIM 62/206). "Sendo conflitante a prova e não podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu" (TACRIM-SP - AP- Rel. Cunha Camargo - JUTACRIM - 20/370). "Sendo impossível optar com segurança entre as versões da vítima e dos acusados, quando nenhuma delas vem alicerçada em alguns outros adminículos objetivo fornecido pelos autos, é impositivo que se decrete a absolvição dos réus" (TACRIM-SP- AP- Rel. Érix Ferreira - RJD 24/37). Face ao exposto requer seja julgado improcedente a ação penal a fim de absolver o réu com fulcro no art.386, VII do CPP, devendo-se aplicar o princípio do *in dubio pro reo*.

**II - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS** A defesa requer a desclassificação da infração para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, pois não ficou comprovado em nenhum momento que a droga era destinada a mercancia, elemento caracterizador do tráfico. Embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, é de se destacar que este dado, neste momento, perde importância, pois a tipificação da conduta perfilha-se no dolo do agente, conforme entendimento jurisprudencial: "Já se tem sustentado que não basta o simples encontro da substância com suspeito para se erigir uma prova de autoria, pois esta deve estar definida em termos de dolo do agente. A posse deve estar ligada ao uso ou ao tráfico.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

Daí o simples encontro corporificar a materialidade do fato que nem sempre é criminoso. A simples posse pode denotar uma presunção de autoria mas esta a de ficar também demonstrada. E, finalmente, o dolo a de ser extraído das circunstâncias para que se autorize uma condenação. (“Os alucinógenos e o Direito - LSD”, Geraldo Gomes, Juriscredi - SP) (TACRIM-SP - AC - Rel. Geraldo Gomes - JUTACRIM 56/238). Há de se considerar o disposto no art. 28, §2º da Lei de Drogas, que prevê que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à **natureza e à quantidade da substância** apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Assim, quando da apreciação do caso concreto, o magistrado deve analisar as circunstâncias pessoais e circunstanciais para capitular a conduta que lhe é apresentada. Nesse sentido, pela desclassificação que ora se requer, dentre inúmeros julgados, cite-se: “APELAÇÃO - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO - USO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Embora restem incontroversas no caderno processual a materialidade e a posse do entorpecente pelo acusado, operada deve ser a desclassificação de sua conduta para o delito do art. 28 da Lei Antitóxicos, quando inexistente nos autos prova inequívoca de que a substância arrecadada em seu poder teria como destino fim a mercancia. Não havendo elemento hábil a ensejar um édito condenatório e não existindo provas concretas a demonstrar a prática pela acusada dos fatos descritos na denúncia, neste sentido, a absolvição é medida que se impõe, na estrita observância do princípio ‘in dubio pro reo’”. (Acórdão nº 1.0223.08.251753-1/001(1) de TJMG. Des. Vieira de Brito. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 23 de Julho de 2009). (Grifo nosso) “APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO - Possibilidade, no caso em tela, de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da lei 6368/76, vez que o apelante foi pego com pequeno valor monetário e ínfima quantidade de droga, que estava sendo usada quando da prisão em flagrante – Apelo provido” (Apelação nº 993.06.020666-4, Des. Relator Salles Vieira. Julgado aos 16 de setembro de 2010). Ainda têm-se: “PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO - POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO - FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA ILÍCITA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO - FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO NO ART. 16 DA LEI 10.826/03 - RECURSO DO MP - IMPROVIMENTO. 1. AUSENTES PROVAS DA MERCANCIA ILÍCITA, SUBSISTINDO APENAS AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, COM **APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA**, A DESCLASSIFICAÇÃO, DE TRÁFICO PARA O USO, É MEDIDA IMPOSITIVA. 2. INEXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE MANter EM DEPÓSITO MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO (ARTIGOS 14 E 16 DA LEI 10826/03), REMANESCENDO, CONTUDO, PROVA DA APREENSÃO DE UMA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

15ª VARA CRIMINAL

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Apelação criminal nº 1214924820048070001 DF 0121492-48.2004.807.0001. TJDF. Relator(a): EDSON ALFREDO SMANIOTTO. Julgamento: 24/09/2007. Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal. Publicação: 16/01/2008, DJU Pág. 708 Seção: 30). (Grifo nosso) Desta forma, pugna-se subsidiariamente pela desclassificação do tráfico de entorpecentes para o uso, descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06. Não ficou comprovado em nenhum momento o dolo do agente, que é elemento caracterizador do tráfico, pois não há nenhum indício da prática da mercancia.

A quantidade encontrada pode corresponder perfeitamente a um estoque pessoal pretendido por aquele que receberia a droga. Sendo assim, de rigor a desclassificação para o crime do art. 28 conforme recomenda a jurisprudência. **III - DA PENA BASE E DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33** A pena deve ser fixada no mínimo em face de todas as circunstâncias. Requer-se, ainda aplicação de diminuição de pena em face da primariedade, dos bons antecedentes do acusado e das demais condições que estão presentes. Prevê o §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos que: *“Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”* A todos esses requisitos o acusado atende (primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem tampouco integra organização criminosa, não havendo, portanto, nada que o desabone). Cabe destacar que se tratando de réu primário e de bons antecedentes, que não ostenta envolvimento com nenhuma organização criminosa, imperiosa a concessão do benefício, não se compreendendo sequer o que pretendeu dizer o legislador quando consignou que aquele que se dedica a atividades criminosas não faz jus a redução de pena. Ora, se o réu não se dedica a nenhuma outra atividade criminosa é ele inocente da imputação de tráfico. Em sentido oposto, se ela exercia o tráfico e é primário, de bons antecedentes, deverá ser condenado, mas fará jus a redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. É o que ressalta o festejado autor de Direito Penal e Processual Penal Guilherme de Souza Nucci: *“Na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique a atividade criminosa. No mais, sendo primário e de bons antecedentes não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita.”* (Obra Supracitada, 2ª Ed., RT, 2007, p. 330). Salvo melhor juízo, nos parece que a única interpretação possível e razoável que pode ser dada a expressão “não se dedicar a atividades criminosas” é aquela que preconiza a aplicação do benefício quando o réu dedica-se a atividades criminosas diversas da que lhe são imputadas no processo por delito de tráfico. Definitivamente não é o caso, portanto, imperiosa a concessão ao réu a diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois em contexto como este a aplicação do desta causa de diminuição de pena é obrigatória, traduzindo-se em




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

autêntico direito subjetivo do réu, conforme ressalta a doutrina: “A redução decorre de antigo anseio dos juristas, a fim de corrigir distorções existentes nas leis anteriores revogadas. Antes da vigência da Lei m. 11.343/2006, qualquer pessoa condenada pela prática de tráfico ilícito de drogas, teria que cumprir, no mínimo, três anos de reclusão, em regime integralmente fechado, possibilitando-se, apenas, a concessão de livramento condicional após cumpridos dois terços da reprimenda. A redução, assim caracteriza significativo avanço legislativo, possibilitando ao julgador analisar, com amplitude, as condições subjetivas do agente, a fim de melhor obedecer ao princípio da individualização da pena. Trata-se de direito subjetivo do réu. Uma vez preenchidos os requisitos legais, a redução é obrigatória, ficando a cargo do juiz a estipulação do quantum a ser diminuído.” (Leis Penais Especiais, Ed. Juarez de Oliveira, 2006, Vários autores, Coordenador Roberto Mendes de Freitas Jr.). **IV – DA APLICAÇÃO DO REDUTOR, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E À GARANTIA DO NE BIS IN IDEM** Neste passo, quanto à incorporação do princípio da proporcionalidade no direito brasileiro, cabe lembrar, de início, que, segundo preleciona Paulo Bonavides, verbis: “No Brasil, a proporcionalidade pode não existir enquanto norma geral de direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A noção mesmo se infere de outros princípios que lhe são afins, entre os quais se avulta, em primeiro lugar, o princípio da igualdade, sobretudo em se atentando para a passagem da igualdade-identidade à igualdade-proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de Direito (...). O princípio da proporcionalidade é, por conseguinte, direito positivo em nosso ordenamento constitucional” (Curso de Direito Constitucional – Ed. Malheiros, p. 395/6). A proporcionalidade estaria, incluída, portanto, na vedação de excessos, ínsita ao art. 37 da Constituição Federal e flui do espírito que anima em toda a sua extensão e profundidade o § 2º, do art. 5º, o qual abrange a parte não-escrita ou não expressa dos direitos e garantias da Constituição. Conclui, assim, Bonavides: “admitir a interpretação de que o legislador pode a seu livre alvedrio legislar sem limites, seria por abaixo todo o edifício jurídico e ignorar, por inteiro, a eficácia e a majestade dos princípios constitucionais. A Constituição estaria despedaçada pelo arbítrio do legislador” (op. cit., p. 396). Acrescenta Alberto Silva Franco, quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito penal: “Num modelo de Estado (Social) e Democrático de Direito, sustentado por um princípio antropocêntrico, não teria sentido, nem cabimento, a cominação ou aplicação de pena flagrantemente desproporcionada à gravidade do fato. Pena desse teor representa ofensa à condição humana, atingindo-a de modo contundente, na sua dignidade de pessoa. O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se em consequência, uma inaceitável desproporção” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, 6ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 36). Neste passo, a Lei nº


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

11.343/06, ao fixar como pena mínima para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, causa de diminuição de 1/6 a 2/3 para primários, acabou por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que integre organização criminosa), como é o caso dos autos, é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela não aplicação da causa de diminuição, pena de 5 (cinco) anos de reclusão. O peso da reincidência é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 da pena, sendo 2/3 aplicados em função da reincidência. Esta desproporção é inconstitucional, ainda, porque aprecia, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência, implicaria a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (em face de seus antecedentes) e não em razão do que o agente faz. Como mostra Muñoz Conde, *verbis*: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Dessa maneira, tal dimensão de acréscimo da pena (a que corresponde à negativa de aplicação da causa de diminuição) ofende a proporcionalidade, na medida em que possibilita aplicação de pena a maior pelos fatos pretéritos do que por aquele a que está sendo imputado ao agente. Nem se diga, por fim, da impropriedade de afastar-se regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas, ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no § 1º do art. 5º, da Constituição (“*O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos*”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juízes para a Democracia, 2001). No mesmo sentido, o ensinamento de Paulo Bonavides: “*A lesão ao princípio é indubitavelmente a mais grave das inconstitucionalidades porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades cujo exercício somente se faz possível fora do reino do arbítrio e dos poderes absolutos*”. (op. cit., p. 396). Ainda que assim não fosse, cabe frisar que a não aplicação do redutor, por força da agravante da reincidência, consubstanciaria autêntico *bis in idem*, já que esta circunstância legal já será reconhecida na segunda etapa de cálculo da reprimenda. Portanto, deve a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ser aplicada em favor do acusado. **V- DO REGIME ABERTO E DA APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS** Prosseguindo sendo o réu indivíduo primário e de bons antecedentes, cabível a fixação do regime inicial aberto. Neste diapasão, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis), não se pode afastar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Também inafastável o direito do réu ter sua pena privativa de liberdade substituída por sanções restritivas de direitos. É que o óbice outrora existente na lei de droga foi suprimido pela resolução do Senado Federal, que cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal, afastou o óbice legal a substituição da pena privativa de liberdade por delito de tráfico por sanção restritiva de direitos. O afastamento da substituição da pena, mesmo em caso de tráficos praticados por indivíduos primários, com bons antecedentes e conduta social adequada, tem por consequência o povoamento de nossas prisões por pessoas sem passagem criminal anterior e sob as quais sequer pesa suspeita de envolvimento com facções criminosas. Por estes motivos, o Senado Federal, através da resolução nº 5 de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Conforme artigo 1º o Senado Federal resolveu: “*É suspensa a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS*”. Neste diapasão, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, quais sejam: I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis), não se pode afastar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Por fim, na sentença deve se observar o disposto no art. 387, §2º do CPP, inserindo-se o réu no regime prisional subsequente, caso se verifique o tempo de prisão provisória em regime equivalente a fechado é igual ou superior a um sexto da pena cominada ou caso a pena restante possa ser cumprida em regime menos gravoso, de acordo com o mais


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao não mais considerar o tráfico privilegiado como crime hediondo, Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública requerer ao colhimento dos pedidos acima expostos."

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte **SENTENÇA**:

**ALLAN BONGESTAB DVORKIN**, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque em 01/06/2016, por volta das 04h00, na Rua Domingos dos Santos Gomes, nº490, Aricanduva, nesta Capital, trazia consigo 11 eppendorfs contendo 26,5g de cocaína (massa líquida de 2,1g), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, momento em que o réu chamou atenção por entrar e sair de um determinado local. O réu foi abordado, sendo encontrados em sua posse os entorpecentes descritos acima, bem como a quantia de R\$ 90,00. Ao ser indagado sobre os fatos, confessou informalmente aos policiais atuantes que vendia drogas no local para sustentar seu vício. Registram-se os principais atos e termos processuais: citação (fls. 61/62), defesa prévia (fls. 66), denúncia recebida em 21 de novembro de 2016 (fls. 71/72) e instrução criminal. É relatório. Decido. **Thyago** testemunhou a prisão na escadaria conj habitacional, ele entrava e saía, abordaram, bolso direito 11 pinos cocaína (pó) e R\$90,00. O depoente estava no começo da escadaria, a pé. De lá via concentração pessoas, cerca de ¾ pessoas, ele descia, virava à direita na rua, voltava para a escadaria. Viu essa movimentação umas três vezes em cinco minutos. Estava meio alterado, acha que tinha usado droga. Confessou ser usuário. Não o viu usando. Não viu entregando droga a alguém. Disse que era para consumo de droga, disse que tinha serviço de manhã, algo a ver com frango. Disse que estava ali usando droga. Eram moradores de rua, com cachimbo de crack, cobertor. Foram até o lado direito, para onde ele se deslocava, nada encontraram. Os outros foram abordados, sendo localizado um cachimbo. **Renata** lembra do Réu, ela e o parceiro patrulhando, sabem que tem venda na escadaria. Viram-no em atitude suspeita, ele entrava e saía da escadaria. Na busca pessoal foram encontrados 11 eppendorfs de cocaína e noventa reais. O réu disse que é usuário, e vende para sustentar o vício. Ele falou quando perguntaram. Havia outras pessoas, não sabe quantas. Alguns foram abordados. Tem um bar na esquina, onde fica bastante gente. Viram subir e descer, não sabe exatamente quantas vezes. Avenida na parte de cima da escada tem duas mãos, passaram por um lado, viram, retornaram pela outra mão. Réu abordado no topo da escada. Lá é ponto de venda, as pessoas param para comprar na avenida. Não viram entregar, vender. Só viram a movimentação na escada. A depoente fez a revista no Réu. Provavelmente o parceiro olhou o local, nada encontrando.


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

Aparentava ter consumido. II – Da análise das provas. A natureza do material apreendido está provada. O Perito constatou 2,1g de material sólido particulado misturado a material petrificado, detectando cocaína (pgs. 86/88). Os depoimentos dos policiais, que detiveram o Réu, provam que ele trazia consigo onze Eppendorfs de cocaína e a quantia de noventa reais. Os depoimentos de Thyago e Renata são uníssonos quanto à autoria do porte da totalidade da droga apreendida. A condição de policiais, por si só, não autoriza desconsiderar os depoimentos das testemunhas. Não se vislumbram motivos para que os policiais acusassem o réu. Os depoimentos são harmônicos e homogêneos, sem motivos de suspeição, nem indícios de que os policiais fossem desafetos do réu, ou que tivessem hostil prevenção contra ele, ou ainda que quisessem indevidamente prejudicá-lo. O STJ já decidiu que os depoimentos de policiais, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório têm idoneidade, conforme a ementa oficial ora transcrita: “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por policiais que realizaram o flagrante.” (RT 771/566). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça já decidiu pela eficácia dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios (RT 754/604). No mesmo sentido, o julgamento da Apelação no. 0000111-90.2012.8.26.0445 – 5, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Voto no. 12.578: “Sobreleva destacar que nada impede que policiais militares, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito. Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.' (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)." O Col. STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Por outro lado, os depoimentos não permitem firmar convicção de que o Réu trouxesse droga consigo para vender. Ambos testemunharam o Réu sob efeito de drogas, o que indica porte para uso próprio. Outro fato presenciado pelas testemunhas foi a movimentação do Réu na escadaria. Segundo Thyago, por três vezes, em cinco minutos, ele saiu da escadaria e voltou para ela. Entretanto, os policiais não pararam para observar. Segundo Renata, passaram pela Avenida, que fica no alto da escadaria, viram o Réu se deslocando, retornaram pela mesma via e abordaram-no na escadaria. Não se sabe a extensão percorrida para retornar até o alto da escadaria, mas me parece que cinco minutos é muito tempo para quem se desloca em veículo motorizado. Ainda segundo Renata, as vendas não acontecem na escadaria, mas sim para as pessoas que ficam no bar,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**

**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

localizado na avenida, ou para as pessoas que param de carro na avenida, para comprar. Os policiais trafegaram pela avenida, mas não presenciaram o Réu entregar droga a quem quer que seja. O único ato típico efetivamente testemunhado é o porte de entorpecente, em quantidade compatível com uso próprio. O depoimento de Renata confirma os elementos do auto de prisão, acerca da confissão informal, o que não tem valor probatório, porque é sabido que, nessas situações, paira densa dúvida sobre a garantia do direito ao silêncio. Julgando o [HC 80949/ RJ](#) - RIO DE JANEIRO HABEAS CORPUS, de que foi Relator o Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, a Primeira Turma do STF analisando a "conversa informal" do indiciado com policiais, concluiu: **III. Gravação clandestina de "conversa informal" do indiciado com policiais. 3. Ilicitude decorrente - quando não da evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu assentimento à gravação ambiental - de constituir, dita "conversa informal", modalidade de "interrogatório" sub- reptício, o qual - além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial (C.Pr.Pen., art. 6º, V) -, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. 4. O privilégio contra a auto-incriminação - nemo tenetur se detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição - além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. - importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em "conversa informal" gravada, clandestinamente ou não. IV. Escuta gravada da comunicação telefônica com terceiro, que conteria evidência de quadrilha que integrariam: ilicitude, nas circunstâncias, com relação a ambos os interlocutores. O acórdão segue analisando a gravação clandestina, o que vai além da situação fática sub judice. No [HC 22.371-RJ](#), de que foi Relator o Ministro Paulo Gallotti (STJ), os depoimentos de delegados de polícia e comissário de polícia, testemunhando a confissão informal, foram tidos como provas ilícitas: **O paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado por tentativa de homicídio, prática que alega simulada, visto ter recebido dinheiro, instruções e suporte material da própria vítima para tal desiderato. Sucede que, quando da lavratura do aludido flagrante, constou dos autos que se quedou silente, nada respondendo. Mas, um dia após o interrogatório, compareceram à delegacia dois delegados e um comissário de polícia, afirmando em depoimento que, no dia da****


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP 01133-020

lavratura, o paciente havia confessado-lhes o crime em conversa informal, fato que não consta sequer da denúncia, que não arrolou testemunhas. Isso posto, na medida em que não há qualquer elemento no supracitado depoimento que se possa extrair que alguma providência tenha sido tomada para acautelar o direito do paciente de não se incriminar, de ficar calado ou de ser acompanhado por defensor, a Turma, por maioria, concedeu a ordem *ex officio* para desentranhar aquela peça incriminatória. Entendeu violado o art. 5º, LVI, da CF/1988, que não admite no processo provas obtidas por meios ilícitos. De qualquer forma, os depoimentos não são uniformes, em relação à confissão, porque Thyago, divergindo dos elementos do inquérito policial, testemunhou o Réu confessar ser usuário, que estava ali usando droga, afirmar que o dinheiro era para consumo de droga, e dizer que tinha serviço de manhã, algo a ver com frango. O conjunto probatório, portanto, não é suficiente para condenar por tráfico, mas sim pelo porte para uso, impondo-se nova classificação aos fatos expostos na denúncia, para condenar o Réu pelo art. 28 da Lei 11343/06. III – das penas. A existência de outro processo por crime da Lei 11343/06 leva a aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, posto que não consta condenação transitada em julgado. IV – do dispositivo. **Ante o exposto, com fundamento no art. 383 do CPP, julgo procedente a ação e condeno ALLAN BONGESTAB DVORKIN como incurso no art. 28 da Lei 11343/06 a cumprir 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.** Seja seu nome lançado no Rol dos Culpados. Publicada em audiência, saem cientes os presentes. Intime-se o Réu. CUMPRA-SE.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pela MM Juíza, consoante o disposto no art. 1.269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo via física entregue às partes ao final dos trabalhos. Os depoimentos prestados em audiência estão documentados em mídia audiovisual, que permanecerá arquivada em cartório. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. Saem todos cientes do teor do presente termo. Eu, Natalia Matschinske De Almeida, Assistente Judiciária, digitei.

MM. Juiz(a):

**Dra. Izabel Irlanda Castro Correia Araújo**

Promotor(a):

**Dr. Fernando Henrique de Moraes Araújo**

Defensor(a):

**Dra. Mônica de Melo**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**COMARCA DE SÃO PAULO**

**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**

**15ª VARA CRIMINAL**

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo/SP - CEP  
01133-020

Réu

**ALLAN BONGESTAB DVORKIN**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**